

0045787-09.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... depois foi processado novamente por tráfico, sendo que ainda não foi condenado pelo novo tráfico de maneira definitiva, não podendo ser utilizado em seu desfavor. Vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 53 DO TJCE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. 1. A ...

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO VIRTUAL

Processo nº:

0045787-09.2017.8.26.00502017/001221

Classe - Assunto

Processo Digital

Documento de Origem:

Autor(a):

Justiça Pública

Ré(u):

MARCOS VINICIUS LIMA DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins*

Aos 21 de fevereiro de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução, Debates e Julgamento 9ª Vara Criminal, a presidência da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara da Criminal, Dra. Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, ao final nomeada, regularmente conectada à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do (a) Dr. Cláudio Cavallini, DD (a). Promotor (a) de Justiça, do réu: MARCOS VINICIUS LIMA DOS SANTOS acompanhado de seu (sua) defensor (a), Dra. Gisela Camillo Casotti Teixeira, Defensora Pública atuante na Vara, das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, PC - ANDRE GECCHERLE TREVISAN e FERNANDO CARDOSO DE FREITAS. Foi oportunizado ao réu e seu (sua) defensor (a) conversa privativa, tendo a MMA. Juíza, Promotor (a) e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando a magistrada e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas, arroladas pela acusação e defesa, acima referidas, respectivamente, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se o réu, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação armazenada em nuvem através do sistema One Drive, após as mídias foram importadas para o sistema SAJ. Iniciados os trabalhos, as partes não se opuseram que a

audiência se realizasse pelo sistema presidencialista. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer nos termos do art. 402 do CPP. Pela Defesa foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer nos termos do art. 402 do CPP.. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (a) foi dito que: alegações orais.

Dada a palavra ao (a) Dr. (a). Defensor (a), por ele (a) foi dito: Mma. Juíza Marcos Vinicius Lima dos Santos foi denunciado por, supostamente, no dia 31 de maio de 2017, por volta das 12h30min, na Rua Dom Vilarés, nº 1, São Paulo, ter em depósito 40,3 gramas de maconha, acondicionados em 10 invólucros plásticos. De acordo com a denúncia policiais receberam notícias de tráfico em uma pista de skate. Dirigiram-se ao local e, em breve campanha, supostamente, viram o réu em movimento de vena de entorpecentes, sendo que as pessoas dele se aproximavam e entregavam algo e o réu dirigia-se a uma parede vasada, retornava e entregava algo. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, na parece localizaram entorpecentes. Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos dois policiais civis. Após, o réu foi interrogado, oportunidade na qual negou a prática delitiva. A pretensão acusatória não merece prosperar. Os policiais civis ouvidos em juízo disseram terem visualizado o réu buscando algo em um muro e entregando a terceiros sendo que, após, encontraram entorpecentes no muro. O policial Fernando afirmou que o réu negou que este estivesse traficando. Entretanto, não consta dos autos ter sido apreendido dinheiro com o réu, não sendo crível que estivesse traficando, inclusive tendo sido abordado por algumas pessoas e com ele não tenha sido localizado dinheiro. Além disso, os policiais disseram que estavam a cerca de 50 metros de distância, do outro lado da avenida, o que impediria que vissem com precisão o que acontecia na pista de skate. Os policiais afirmaram que havia outras pessoas no local, o que foi confirmado pelo réu, que disse estar próximo a outros indivíduos e que estava fumando maconha. Também não foram ouvidos supostos compradores. Assim, não restou comprovado que o réu estivesse de fato exercendo a traficância, sendo crível sua versão de que tenha sido confundido com outros indivíduos por estarem com roupas escuras parecidas, sendo de conhecimento amplo que indivíduos que frequentam tais ambientes realmente vestem roupas largas e escuras. Subsidiariamente, em caso de remota condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal cominado. Na segunda fase da dosimetria requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por fim, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado considerando que, à época dos fatos o réu era primário e de bons antecedentes e não detinha nenhum processo sequer em andamento por tráfico. Ressalte-se que o crime é um fato estático, sendo que processos posteriores não podem fazer presumir, que à época do delito apurado nestes autos, o réu era indivíduo envolvido na prática criminosa. Saliente-se que apenas 03 anos depois foi processado novamente por tráfico, sendo que ainda não foi condenado pelo novo tráfico de maneira definitiva, não podendo ser utilizado em seu desfavor. Vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AÇÕES PENAS EM ANDAMENTO E CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 53 DO TJCE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. 1. A existência de ações penais ou condenações por fatos posteriores, ainda transitadas em julgado, não justificam o afastamento do tráfico privilegiado, haja vista que não demonstram que, até a conduta perscrutada na ação penal, o agente dedicava-se à atividade criminosa, ostentava maus antecedentes ou era reincidente. Súmula 53 do TJCE e precedentes desta Câmara. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0158636-63.2016.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 14 de dezembro de 2021 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (TJ-CE - APR: 01586366320168060001 CE 0158636-63.2016.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento:

14/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2021) Tráfico - Suficiência de provas - Condenação. Associação para o tráfico - Possibilidade de mero concurso eventual entre os agentes - Falta de "animus" associativo - Absolvição mantida. Exasperação das penas-base - Quantidade da droga - Impossibilidade - Volume igualmente considerado na terceira etapa do cálculo. Antecedentes - Certidões que indicam feitos em andamento, condenações muito antigas ou relativas a fatos posteriores - Não configuração. Privilégio - Possibilidade - Corréu primário e absolvido do delito de associação - Critérios - Art. 42 da Lei de Drogas. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Cabimento. Tráfico privilegiado - Hediondez afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 118.533. Parcial provimento aos recursos defensivos e não acolhimento do apelo ministerial. (TJ-SP 00019767520158260597 SP 0001976-75.2015.8.26.0597, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 25/04/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/05/2018). Caso afastado o redutor apenas por processos posteriores, será equipará-los à reincidência, o que se mostra inviável. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena.

A seguir, pela MMª Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Marcos Vinícius Lima dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque supostamente em 31 de maio de 2017, por volta de 12h30min, na Rua Dom Vilarés, n.º 1, nesta Capital, tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 40,3 gramas de Cannabis sativa L (maconha), acondicionados em 10 (dez) invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida às fls. 61/62, o acusado foi citado à fl. 131, apresentou defesa à fl. 136 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 138), momento em que ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A ação penal é procedente eis que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia. A materialidade restou demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fl. 11, laudo de constatação de fls. 13/14, laudo do exame químico-toxicológico de fls. 80/82, bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria também restou demonstrada. Coram iudice o réu negou a imputação. Disse que no dia dos fatos estava trabalhando entregando panfletos numa pizzaria da região e na hora do almoço foi à pista de skate, estava fumando "maconha" quando os policiais chegaram. Haviam outros indivíduos com roupa escura ao seu lado, razão pela qual acredita que tenha sido confundido. Não conhecia os policiais anteriormente. Tal negativa, contudo, restou isolada e desmentida pelos demais elementos dos autos. Com efeito, o policial civil Fernando Cardoso de Freitas afirmou que no dia dos fatos foi até o local onde fica um ponto de skatistas e venda de drogas. Permaneceu em campanha numa viatura descaracterizada por cerca de 30/40 minutos período em que avistou o réu praticando ato típico de mercancia, eis que pessoas se aproximavam dele lhe entregavam algo e ele ia até um muro pegava alguma coisa e entregava para a pessoa. Visualizou três ou quatro pessoas se aproximando do réu. Quando foi realizar a abordagem o réu correu, mas o perseguiu e o deteve. No buraco do muro foi encontrada a substância entorpecente apreendida - "maconha" -. Questionado, o réu disse que estava somente andando de skate, mas sequer skate tinha. Não conhecia o réu anteriormente. Já o policial civil André Geccherle Trevisan afirmou se recordar apenas vagamente do réu e que o local funcionava um ponto de tráfico. Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais civis que prenderam o acusado em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer

conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Ainda: "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273). "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275). Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). Por fim, a quantidade de substâncias apreendidas - 40,3 gramas de "maconha", acondicionados em 10 (dez) invólucros plásticos - bem como as circunstâncias e local da abordagem, não deixam dúvidas que os entorpecentes se destinavam inequivocamente à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta, ao artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Assim é que decido. Passo, portanto, à fixação da pena. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, c.c. artigo 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que o acusado é menor relativo, contudo, sem reflexo na pena, de acordo com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Observo, outrossim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4.º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que o réu é à época dos fatos era primário e não foi surpreendido com grande quantidade ou variedade de substância entorpecente, razão pela qual não se pode presumir que o réu à época se dedicasse de forma habitual ao tráfico de entorpecentes ou que integrasse organização criminosa; assim diminuo a pena em dois terços (2/3), resultando em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, que torno definitiva. O regime inicial para desconto da reprimenda privativa de liberdade deve ser o aberto, em razão da quantidade de pena aplicada e primariedade do réu à época dos fatos (artigo 33, do Código Penal). Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar Marcos Vinícius Lima dos Santos, qualificado nos autos, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no artigo 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/06. O réu respondeu em liberdade, razão pela qual poderá apelar da mesma forma. Deixo de substituir a reprimenda corporal por restritiva de direitos, eis que após os fatos o réu foi condenado em outros processos criminais e encontra-se preso em cumprimento de pena, fato que demonstra que tal medida não se mostra socialmente recomendável e inviável o cumprimento de tal medida. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas. Isento de custas. Publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (a) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, este (a) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Defensor (a), foi dito: Ciente da sentença. Não desejo apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de não recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Diante da ausência de recursos pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado. Providencie-se o necessário em relação à multa imposta, nos termos das Normas do Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, expeça-se a guia de recolhimento definitiva. Cumpra-se o quanto determinado na sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as comunicações necessárias e a observância das formalidades legais. Saem os presentes intimados.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.